

1500885-12.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... no local na qualidade de olheiro do tráfico. Ele portava um rádio na oportunidade.

Em juízo o acusado alegou que atuava na condição de olheiro do tráfico, mas sem estar propriamente traficando.

Não convence sua versão judicial para os fatos; vejamos.

É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500885-12.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500885-12.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120403/2022 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 24723547 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 2120403 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Pereira Cruz da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

JONATHAN PEREIRA CRUZ DASILVA, qualificado às fls. 04 e 06/07, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de maio de 2022, por volta das 15h30, na Travessa Beirute, altura do nº 6, bairro do Canhema, nesta cidade e comarca de Diadema, , trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 33 embalagens plásticas contendo 16,76g da droga cocaína, e 43 embalagens plásticas contendo 13,98g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 41 e laudo de constatação provisória de fls. 45/46, agindo sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 66/69). Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 02/08/2022 (fl.160) e certificadas a notificação e a citação positivas do Réu (fls.141 e 194), sendo apresentada defesa prévia pelo Defensor Público às fls. 150/151.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga, em que pese a confissão do réu, o que não deve preponderar sobre a multirreincidência, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, com a perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta do réu para a figura prevista no artigo 37 da Lei de Drogas, bem como que a pena-base seja fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.
Passo a fundamentar e decidir.

Ausentes matérias preliminares, a ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.41, nos autos de constatação e no definitivo (fls. 45/46 e 203/205), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls.02/03) com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, diligenciaram com uma viatura descaracterizada até a Travessa Beirute, aonde estacionaram a viatura próximo e se dividiram, seguindo cada policial por um dos acessos da citada Travessa. Relatou que seguindo pela Travessa conseguiu visualizar um indivíduo exatamente no local onde costuma ficar o “vapor”, pessoa responsável pela venda da droga, e seguiu em sua direção, porém o indivíduo também conseguiu visualizar a sua aproximação e jogou uma pequena bolsa de cor cinza que trazia consigo, no chão e saiu correndo, sem perceber a aproximação do policial William pelos sentido contrário, que logrou êxito em abordá-lo. Relatou que efetuaram a abordagem e em busca pessoal foram localizados o valor de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais), dois invólucros de substância esverdeada semelhante a maconha e dois invólucros de pó branco assemelhado a cocaína, verificando o conteúdo da bolsa, a mesma continha vários invólucros de substância assemelhada a cocaína e maconha, identificaram o indivíduo como sendo JONATHAN PEREIRA CRUZ DA SILVA, questionando-o sobre as drogas com ele

localizadas, tendo o mesmo imediatamente assumido a traficância, declarante que ficaria naquele local até as 18 horas.

Sob o crivo do contraditório o policial Willian Divetta Carrieri reiterou que o local é ponto de venda de drogas; em viatura caracterizada desempenharam as diligências, e abordaram o réu na posse de dinheiro e drogas. O policial Adriano terá visto ele dispensar uma bolsa, onde localizados entorpecentes similares aos que estavam na posse do réu, que confirmou os fatos em que fundada a pretensão punitiva. O local ainda é ponto de venda de drogas de forma reiterada.

Neste mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Adriano Moreira Ponte. Cada policial desembarcou por um lado da via em que ocorreram as diligências. Ao avistar o depoente, o réu empreendeu fuga e trombou com o outro polícia, William, ao que foi detido. Somente o acusado correu quando dos fatos. Confirma os demais fatos narrados pelo policial Willian.

O réu, em solo policial (fl.04), confessou, declarando que ficaria naquele ponto das 10 às 18 horas, recebendo ao final do seu turno o valor equivalente a 10% do valor arrecadado com a venda das substâncias, o que dá em média o valor de R\$ 100,00 (cem reais). Declarou que vendia o invólucro de cocaína por R\$ 10,00 (dez reais) e o invólucro de MACONHA por R\$ 5,00 (cinco reais). Declarou que sempre chega no local para a venda das drogas no horário combinado e um indivíduo desconhecido aparece no local e lhe entrega uma pequena bolsa com as drogas e passa no decorrer do dia, em horários incertos para recolher os valores arrecadados. Por fim declarou que estava no referido ponto de drogas, quando percebeu a aproximação de um indivíduo, que parecia ser policial, então passou a seguir para o sentido inverso, percebendo que o indivíduo acelerou o passo, se desfez da bolsa e correu, mas foi abordado por outro policial que vinha pelo outro lado da travessa, então localizaram as drogas e o trouxeram até a unidade policial.

A testemunha Vera Lúcia, por sua vez, disse ter presenciado a abordagem, e que o réu estaria no local na qualidade de olheiro do tráfico. Ele portava um rádio na oportunidade.

Em juízo o acusado alegou que atuava na condição de olheiro do tráfico, mas sem estar propriamente traficando.

Não convence sua versão judicial para os fatos; vejamos.

É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Isso porque: o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares ter em depósito e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Ficou comprovado ainda que o dinheiro encontrado com o acusado consistia em cédula de pequeno valor. Não é desconhecido que na venda de entorpecente é utilizado dinheiro miúdo correspondente ao valor da porção de maconha que está sendo adquirida. Isso confere a rapidez e a agilidade necessárias para que o adquirente e o vendedor não fiquem expostos a guarnições de viaturas em policiamento preventivo ou a campanas da polícia civil, permitindo a imediata fuga, para dificultar a prova da traficância.

Acrescento que o réu não comprovou a origem lícita do numerário com ele apreendido, pelo que, deve ser reputado como produto da traficância.

Cabe apontar que além da confissão colhida em solo policial, a testemunha indicada pela D. Defesa que ampararia a versão de que o réu atuaria como mero colaborador não encontra guarida em relação aos demais elementos de prova, que indicam de forma firme a atuação do réu como traficante, e não como mero colaborador. Referida testemunha não acompanhou toda a diligência, além de não poder indicar as circunstâncias, de forma detalhada, em que ocorrida a prisão do réu, que trazia drogas e dinheiro consigo, corroborando seu envolvimento com o núcleo do tipo do tráfico.

Neste sentido, sem razão as teses defensivas, em que pese o quanto sustentado, seja pela absolvição, seja pela desclassificação.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (76 no total) o que não reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, ostentando o réu maus antecedentes, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente a circunstância agravante da multirreincidência (fls. 50/53), sendo certo que, a despeito da versão oferecida em Juízo, o réu é confesso, conforme fatos narrados em solo policial. Assim, compenso a condenação comprovada a fl. 51(Roubo junto à 3ª Vara Criminal de Diadema) com a atenuante da confissão espontânea, que por envolver a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" (STJ, REsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012). E considerando a outra condenação, roubo, junto à 24ª Vara Criminal de Barra Funda/SP, agravo a pena em 1/6, valendo-me do princípio da proporcionalidade e para uma mais justa individualização da pena considerando a reiteração delitiva, perfazendo 06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, a indicar que faz do crime seu meio de vida, tanto que apreendido dinheiro a não deixar dúvida da traficância, de modo que inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja

primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018).

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente é reincidente específico). Ademais: “Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT 772/617.

Atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, assim como a preponderância da natureza e da quantidade das drogas, de alto poder viciante e degradante da saúde humana, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional.” (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019.)

Custodiado no curso do processo, o réu não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, sendo mais adequado que o Juízo da Execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obterá um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de três meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal

(que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória. Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra JONATHAN PEREIRA CRUZ DA SILVA, qualificado às fls. 04 e 06/07, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena 06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 680 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade.

Sendo ele beneficiário de acesso gratuito à Justiça, reconheço suspensão a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fls.41 e 85), com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA